

0000820-98.2017.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada

Vara Única

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, 1001, Nova Granada-SP - cep 15440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000820-98.2017.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000820-98.2017.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 165/17 - Delegacia de Polícia de Icem, 209/2017 - Delegacia de Polícia de Icem, 38/2017 - Delegacia de Polícia de Icem

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALBIERI

Vistos.

THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA, qualificado às fls. 32/35, e JORGE PAULO NUNES, qualificado às fls. 36/40, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e 35, todos da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 29 de julho de 2017, por volta das 17h45min, na Rua Papa João Paulo XXIII, nº540, Centro na cidade de Icem/SP, nesta comarca de Nova Granada, transportavam, com o fim de tráfico ilícito, 56 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 11,592g (fls. 28/29), além de 01 porção de Cannabis sativa L, conhecida como 'maconha', com peso líquido de 5,970g (fls. 30/31), drogas causadoras de dependência química ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta na denúncia, os denunciados JORGE e THIAGO são moradores da cidade de Altair/SP e, após adquirirem droga de pessoa desconhecida, na cidade de

Barretos, rumaram para a cidade de Icem/SP, onde pretendiam comercializar droga, demonstrando o conluio estável para a prática do comércio ilícito de drogas, com certa organização e divisão mínima de tarefas.

Quando chegaram à cidade de Icem/SP, foram abordados pela Polícia Militar, que realizava a operação "Cavalo de Aço", para fiscalização de motocicletas.

Foi realizada busca pessoal nos denunciados e nada de ilícito foi encontrado. Por sua vez, realizada busca no veículo, os policiais militares encontraram 56 (cinquenta e seis) epeendorfs contendo cocaína, além de 01 (uma) porção de 'maconha', todas acondicionadas dentro de um tênis pertencente a Thiago, prontas para o consumo de terceiras pessoas. Além disso, foi encontrada quantia em dinheiro.

A droga foi apreendida e dada voz de prisão em flagrante aos denunciados, que foram encaminhados à autoridade policial.

A denúncia foi instruída com o inquérito policial, contendo as seguintes peças: auto de prisão em flagrante de ambos os acusados (fls. 02-03), termo de depoimento dos policiais (fls. 4/6), termo de interrogatório dos acusados (fls. 7/10), nota de culpa (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 17/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/25), laudo de constatação (fls. 28/31), auto de qualificação (fls. 35 e 40), laudo químico-toxicológico (fls. 48/53), comprovante do depósito do valor encontrado com os acusados (fls. 54/55), relatório final (57/60), manifestação do MP requerendo a incineração do entorpecente e a prisão preventiva dos acusados (fls. 61/65 e 70/75), concessão de liberdade provisória (fls. 124/125), alvarás de soltura cumpridos (fls. 126/127 e 135/139) e mandados de prisão cumpridos (fls. 140/141).

Foi realizada audiência de custódia com os acusados THIAGO e JORGE no dia 30 de julho de 2017, dia seguinte em que foi homologado o Auto de Prisão em Flagrante, convertido o flagrante em prisão preventiva dos acusados (fls. 112/113), expedindo-se o mandado de prisão (fls. 114/115).

O réu Jorge constituiu advogado que requereu a concessão da liberdade provisória, que foi concedida para ambos os acusados, aplicando-lhes as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal (fls. 124/125).

A denúncia foi recebida em data de 04.12.2017, mesma ocasião em que foi indeferido o pedido de prisão preventiva requerido pelo Ministério Público, bem como determinou-se a citação dos acusados (fls.149/150).

Laudo pericial cautelar acostado dos autos (180/182), bem como laudos periciais de constatação e químico-toxicológico da droga (fls. 28/31 e 48/53).

Citados os réus (fls. 189 e 200/204), foi nomeado defensor para Thiago (fl. 216 e 221) e Jorge constituiu o seu defensor, tendo ambos apresentados defesas prévias (fls. 227/234 e 236/242).

Acostou-se petição aos autos requerendo a restituição do veículo antes apreendido (fls. 151/154 e 161/179). O Ministério Público opinou pelo deferimento, condicionado ao depósito em juízo do valor pertencente à pessoa que financiou o automóvel (fl. 208). O pleito foi indeferido através da decisão de fls. 214/215. Não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), foi designada audiência de instrução e julgamento na forma do art. 399 e seguintes do Código de Processo Penal (fls. 246/247).

Constituídos novos defensores para o réu Thiago (fls. 290/291 e 294).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, estiveram presentes os réus e uma das testemunhas de acusação, ocasião em que o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha ausente, sendo designada uma nova audiência de instrução (fls. 308/310).

Na data de 22/10/2019, foi realizada nova audiência, oportunidade em que foi ouvida a testemunha, bem como interrogados os réus (fls. 348/351).

Determinada a instauração de incidente para realização de exame de dependência toxicológica dos acusados (fls. 353/354).

Juntado dos autos Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, referente ao fato de terem abordado o réu Jorge, que estava em um estabelecimento comercial comprando cerveja (fls. 362/366), descumprindo a medida cautelar (fls. 124/125). O Ministério

Público se manifestou requerendo a revogação da liberdade provisória e que fosse decretada a sua prisão preventiva (fls. 375/377), sendo esta decretada (fls. 385/386).

Expedido mandado de prisão em desfavor do réu Jorge (fls. 390/392), a defesa manifestou-se requerendo a revogação da prisão preventiva e o reestabelecimento da liberdade provisória (fls. 398/400), ocasião em que o Ministério Público manifestou-se discordando do pedido (fls. 414/415) e o Juízo decidiu também por indeferir o pedido e manter a prisão preventiva decretada (fls. 416/417).

Impetrado Habeas Corpus pela defesa em favor do réu Jorge (fls. 424/431) e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revogou a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória com cautelares (fls. 455/459).

Laudo pericial "IMESC" referente ao réu Jorge juntado dos autos (fls. 471/477) e, quanto ao laudo pericial do réu Thiago, tornou-se preclusa a prova pericial, por ele não ter comparecido na data e local indicados para a realização da perícia, sem justificativa, bem como por não haver qualquer pedido da defesa (fl. 494).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou que seja julgada parcialmente procedente a presente ação para a condenação nos termos da denúncia com o aumento da pena-base pela natureza e quantidade da droga e a fixação de regime inicial fechado diante da gravidade em concreto da conduta (fls. 516/521).

Tanto a defesa de Thiago quanto a de Jorge requereram em suas alegações finais a desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei, a do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, absolvição em relação ao art. 35 da lei citada, bem como o direito dos acusados apelarem em liberdade, caso haja a condenação (fls. 522/530 e 534/539).

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. Na situação sob julgamento, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/03, pelo boletim de ocorrência de fls. 17/21, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 22/25, que comprova a apreensão de 56 porções de cocaína e uma porção de maconha, além da quantia de R\$ 37,00, pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 28/31 e pelo laudo pericial de fls. 48/53, em que foi constatada a quantidade de 11,592g da substância Cocaína e 5,970g de "Maconha", bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que os acusados Thiago e Jorge foram os autores do crime, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Ouvido em juízo, a testemunha da acusação e Policial Militar, Márcio Aparecido Devechi, disse que na data dos fatos estava em serviço juntamente com o "Cabo Bruno", realizando a operação "cavalo de aço", oportunidade em que abordava os veículos que trafegavam pela via pública onde estava. Em dado momento efetuou-se a abordagem do veículo "Tucson", sendo que estava em seu interior dois indivíduos, ocasião em que reconheceu a pessoa de Jorge, morador de Altair/SP, conhecido por supostamente realizar a venda de drogas na cidade em que reside. Que realizada a busca pessoal nos indivíduos nada foi encontrado, no entanto ao realizarem a busca veicular encontrou-se a substância "cocaína", acondicionada em uma sacola plástica, dentro de um tênis que estava solto no interior do carro, sendo o calçado pertencente a um dos acusados, nada mais foi encontrado no veículo. Informa que os réus alegaram terem ido até a cidade de Barretos/SP, para buscarem os entorpecentes para uso próprio, acreditando o depoente que na realidade os acusados pegaram a droga em alguma cidade próxima como Fronteira/MG ou até mesmo na cidade de Icém/SP.

Informa que Thiago portava a quantia em dinheiro de aproximadamente R\$37,00 (trinta e sete reais) e no veículo havia algumas notas de R\$2,00 (dois reais), bem como que Jorge era o condutor do automóvel. Recorda-se que naquela data estava acontecendo a feira-livre na cidade, o que motivou a criação do bloqueio estratégico da via, para a fiscalização de trânsito. Que não encontrou nenhum objeto que pudesse ter sido utilizado para o uso de entorpecentes. Relata não sabe se Jorge tem "antecedente", mas que alguns de seus amigos policiais chegaram a lhe falar que Jorge comercializava drogas no município de Altair/SP. Alegou que não trabalha mais com o "Cabo Bruno", por este ter sido transferido para a cidade de São José do Rio Preto/SP, e que não conversaram sobre o processo em questão.

No mesmo sentido se deram as declarações do seu colega de farda, também testemunha da acusação e Policial Militar, Bruno Siqueira dos Santos, disse que na data dos fatos estava em serviço, realizando fiscalização de trânsito, bloqueando a via pública, quando abordou dois indivíduos em um veículo, o qual não se recorda a identificação das placas. Que realizada a busca veicular encontrou-se a substância "cocaína", fracionada em 56 unidades, dentro de um tênis que estava solto no interior do carro, sendo pertencente a um dos acusados. Relata que não se recorda quanto ao fato de ter encontrado a "maconha", quantia em dinheiro ou celulares. Que não conhecia os acusados, mas que seu companheiro de serviço conhecia um deles por ocorrência anterior, referente ao delito de tráfico de drogas, salvo engano, no município de Altair/SP. Informa que Thiago estava como passageiro do veículo e Jorge como o condutor. Por fim relata que antes da busca os réus diziam não ter nada no interior do veículo, e ao serem encontradas as substâncias alegaram que eram usuários de drogas, porém nenhum deles assumiu ser o dono único da substância encontrada.

Em primeiro lugar, merece maior crédito a narrativa policial, desprovida de incoerências e de suspeita de interesse dos milicianos na causa (não há razão para acusarem injustamente os réus). Não há motivos para invalidar o depoimento dos policiais ouvidos em juízo.

Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.

Neste sentido, não há motivo para excluir-se o depoimento prestado por agente público. Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995).

Portanto, não se pode excluir o depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade. Por tais motivos, o depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse diapasão, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações"- STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.CONDENÇÃO EM

SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.
2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.
4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento.
5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP.
6. Ordem denegada.

(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) - grifou-se.

Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato - (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de

delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos). Interrogado o réu, Jorge Paulo Nunes, nega ter realizado ou tido a intenção de realizar o delito de tráfico de drogas. Disse que era usuário de drogas e que na data dos fatos encontrou-se com Thiago na cidade de Altair/SP, sendo que iriam ficar por ali, porém não encontraram entorpecentes para comprarem. Decidiram, então, ir até a cidade de Barretos/SP, onde compraram quatro unidades dos entorpecentes, ocasião em que fizeram o uso das substâncias e deram uma "volta" pela cidade. Posteriormente, retornaram ao local, e devido ao baixo valor dos entorpecentes, adquiriram mais quantidades, alegando o réu que utilizariam em um rancho no "veraneio", localizado na cidade de Fronteira/MG, onde passariam dois ou três dias, devido ao fato de que estava de folga do seu serviço naquela ocasião. Relata que estava apenas com o seu cartão de crédito, e que Thiago efetuou o pagamento pelas substâncias, pois tinha o dinheiro. Informa que após efetuarem a compra, tomaram destino a Fronteira/MG, no entanto ao chegarem à cidade Icém/SP, resolveu abastecer seu veículo, pelo fato de que o valor do combustível na cidade de Fronteira/MG era mais alto. Que ao se aproximarem do posto de gasolina onde realizaria o abastecimento, foi abordado pelos policiais, que revistaram o veículo e localizaram a droga dentro de um tênis, onde estava guardada. Consigna que não iria vender os entorpecentes, sendo estes apenas para o seu consumo e de Thiago. Informa que não é mais usuário de drogas, porém há momentos em que se tem recaídas e faz o uso das substâncias. Que já pensou em se internar para tratamento, mas devido ao seu trabalho e por ter que pagar pensão alimentícia para dois dos seus três filhos, considerou algo que só complicaria mais a sua situação. Por fim relata que nunca escondeu o seu vício em drogas, e que conhecia o policial Marcio, sendo que tanto este quanto outras pessoas já havia lhe dado conselhos para que tratasse o seu vício.

Interrogado o réu, Thiago dos Santos Oliveira Rosa, nega ter realizado ou tido a intenção de realizar o delito de tráfico de drogas. Disse que na data dos fatos estava andando pela cidade de Altair/SP, após chegar do trabalho, quando encontrou Jorge na rua, este que lhe convidou para entrar em seu veículo e, posteriormente, saíram à procura de entorpecentes para ambos usarem. Relata que não encontrou a substância na cidade de Altair/SP, ocasião em que foram para Guaraci/SP, onde abasteceram o veículo, e decidiram ir até a cidade de Barretos/SP. Informa que em Barretos/SP, foram até um local denominado "predinho", onde compraram aproximadamente 05 "pinos" de cocaína, oportunidade em que fizeram o uso da substância e deram uma "volta", indo a um bar daquela cidade. Que posteriormente retornaram ao local, com a intenção de comprarem mais 10 "pinos", ocasião em que estava conversando com uma ex-namorada por telefone, esta que o chamou para ir ao "veraneio" na cidade de Fronteira/MG, momento em que Jorge aceitou ir também.

Relata que lhes foram oferecido a quantidade de 60 pinos de cocaína pelo valor de R\$10,00 (dez reais) cada, sendo que o valor cobrado normalmente era de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, tentados pela oferta, foi até o banco onde sacou o valor equivalente para realizar a compra, com a condição de que Jorge pagaria a sua parte quando recebesse o pagamento de seu salário. Após adquirirem os entorpecentes seguiram em direção a Fronteira/MG, entrando na cidade de Icém/SP apenas para a abastecerem o veículo em que estavam devido ao fato de que o combustível teria um valor mais alto na cidade de Fronteira/MG. Quando se aproximaram do posto de gasolina foram abordados por policiais militares que fizeram a revista no veículo, ocasião em que encontraram os "pinos" e a maconha que também lhe pertencia para o consumo próprio. Informa que está tentando sair do vício em drogas, mas que ainda sofre algumas recaídas. Por fim relata que veículo era de Jorge e que o conhecia há pouco tempo.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório. Dos depoimentos acima transcritos, infere-se, além de qualquer dúvida razoável, que as drogas apreendidas nas fls. 2/3 eram de posse de ambos os réus.

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes – condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria – Pena-base fundamentadamente exasperada – Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena – 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos).

Desse modo, tem-se que os Réus transportavam, traziam consigo e/ou guardavam drogas que se destinavam para consumo de terceiros.

Da análise do tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, deve-se observar que a lei não define o que seja traficância. A tal noção, porém, se chega, ao afastar a hipótese de que a posse da droga se destina para o consumo pessoal. Em outras

palavras, pela legislação vigente, haverá tráfico quando não houver consumo pessoal. A Lei de Drogas estabelece alguns critérios que devem guiar a cognição do juiz ou juíza no sentido da determinação do significado do fato penalmente relevante:

Art. 28. (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Com efeito, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína), a quantidade (56 pendorfs com peso líquido de 11,592g), a forma de acondicionamento da substância entorpecente (embaladas prontas para a comercialização) e as circunstâncias pessoais dos Réus (um deles, como dito pelo policial militar em audiência, conhecido dos meios policiais por exercer a traficância), infere-se situação que não retrata porte para consumo pessoal.

Por outro lado, não restou comprovada a prática do crime de associação para o tráfico.

O mero concurso de pessoas (CP, art. 29) para a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 não induz necessariamente à existência de uma associação para tanto. A configuração do delito do art. 35 da mesma Lei exige a união estável e permanente, assim como o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS - EXISTÊNCIA DUVIDOSA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas; não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus em comprovar tais circunstâncias, imperiosa a manutenção da absolvição dos apelados pelo referido crime. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.159412-9/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/06/0020, publicação da súmula em 19/06/2020) Não há provas suficientes de que a união entre os acusados era estável e permanente. À vista de todos esses elementos, conclui-se que os réus THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA e JORGE PAULO NUNES, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticaram parcialmente os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No entanto, as provas foram suficientemente apresentadas e, comprovam o teor da ilicitude através dos autos produzidos durante a fase policial e processual, quanto a quantidade do entorpecente e a forma de seu acondicionamento.

Além disso, inexistem nos autos qualquer elemento que aponte que ele agiu de forma justificada. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto aos autores, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que os réus suscitaram a existência de dirimentes, alegando terem dependência química e, diante disso, foi instaurado o incidente para a realização de exame de dependência toxicológica para ambos, ocasião em que compareceu a perícia apenas o réu Jorge e restou comprovado pelo laudo ser é imputável. (fls. 471/477)

"(...) Não apresenta ausência ou diminuição da pilosidade nasal ou lesões físicas, que estariam obrigatoriamente presentes em caráter permanente, em decorrência da quantidade, frequência e tempo de uso de drogas alegado (critérios físicos), não havendo, portanto, dependência de álcool ou drogas, sendo considerado, sob a óptica

médico-legal psiquiátrica, IMPUTÁVEL para o delito descrito na denúncia."

Quanto ao exame de dependência toxicológica do réu Thiago, tornou-se preclusa a prova pericial, por não ter sequer justificado a impossibilidade de comparecimento e por não haver qualquer pedido da defesa.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto os réus são imputáveis e dotados de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa. Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA e JORGE PAULO NUNES pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como a absolvição de ambos quanto a acusação do crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35, da Lei 11.343/06 e no art. 288, do Código Penal.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes, a presente circunstância não pode ser valorada negativamente, uma vez que não há antecedentes; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: não há razões para serem consideradas negativas, não sendo a natureza bastante, por si só, para elevar a reprimenda, uma vez que este juízo filia-se ao entendimento de que os requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade) são cumulativos. Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para cada Réu.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, anotando-se que não merece incidência a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu apenas admitiu ser usuário de drogas, contudo, negou a traficância (STJ, Súmula nº 630).

Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 para ambos os acusados, sobretudo diante da ausência de comprovação de que os réus se dedicam a atividades criminosas e/ou integram organização criminosa, bem como considerando o fato de não possuírem anotações penais idôneas a gerar antecedentes/reincidência na forma consignada nos parágrafos supra. Isto posto, ausente qualquer elemento concreto em prejuízo dos réus, a pena intermediária deve ser diminuída na fração máxima de 2/3, ficando definida em 01 ano e 08 meses de reclusão e 180 dias-multa. O valor do dia multa é fixado no mínimo legal, por ausência de qualquer informação sobre a capacidade econômica dos acusados.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Impede salientar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Considerando que os réus preenchem os requisitos do art. 44, I a III, do CP,

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP, e a prestação pecuniária de 02 salários mínimos, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR os réus THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA e JORGE PAULO NUNES, pela prática do crime tipificado no caput do art. 33, c/c §4º, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto e ao pagamento de 180 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando, entretanto, que os réus preenchem os requisitos do art. 44, I a III, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade de ambos os acusados por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, e a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA de 02 salários mínimos, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP). Por outro lado, ABSOLVO os acusados do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, VII, do CPP.

CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art.804). Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva do réu por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porquanto foi condenado a pena a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. Autorizo a destruição da substância entorpecente apreendida.

Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Considerando a demonstração de que o veículo apreendido (fl. 24) foi utilizado para o tráfico de drogas, sobretudo para o transporte das drogas apreendidas nestes autos, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento do bem em favor da União. Anote-se que, embora o veículo esteja em nome de pessoa estranha à relação jurídico processual, o veículo foi apreendido na posse de um dos réus. Some-se a isso o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). Ademais, "(...) A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Assim, havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário,

porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita(...)"AgRg nos EDcl no REsp.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e como trânsito em julgado intime-se os réus para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais.

Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nova Granada, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA